

1048457-71.2022.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: FLAVIA POYARES MIRANDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 43ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONSUMIDOR. ROUBO DE CELULAR CONTENDO APLICATIVO DO BANCO RÉU. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. Consumidor vítima de roubo de celular. Terceiro que logrou, via aplicativo da instituição ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

43ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1048457-71.2022.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1048457-71.2022.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Shlomo Tawil

Requerido:

Nu Pagamentos S/A

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FLAVIA POYARES MIRANDA

Vistos.

Shlomo Tawil, moveu ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela em face de Nu Pagamentos S/A, alegando, em síntese, que sofreu furto e através do aplicativo de seu celular foram realizadas diversas operações que não reconhece. Pugna pelo julgamento da procedência condenando-se a parte requerida no pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Foi deferida a tutela de urgência a fls. 41/42.

O réu contestou o feito a fls. 82/96 impugnando a pretensão autoral. O requerido não tem responsabilidade pelo ocorrido. Pleiteia o julgamento da improcedência.

Houve réplica - fls. 116/123.

É, em síntese, o relatório.

Fundamento e decido.

Possível o julgamento no estado do processo, nos termos do artigo 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois a questão, de direito e fática, está suficientemente dirimida através da prova documental constante dos autos.

Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. 1. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. Desse modo, não há incompatibilidade entre o art. 400 do CPC, que estabelece ser, via de regra, admissível a prova testemunhal, e o art. 131 do CPC, que garante ao juiz o poder de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010) grifos nossos

"PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA POSTULADA. REEXAME. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sendo o magistrado destinatário final das provas produzidas, cumpre-lhe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, indeferindo as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 130, parte final). 2- A mera alegação de haver o juízo sentenciante julgado antecipadamente a lide, com prejuízo da produção das provas anteriormente requeridas, não implica, por si só, em cerceamento de defesa. 3- Indagação acerca da imprescindibilidade da prova postulada que suscita reexame de elementos fático-probatórios da causa (Súmula nº 7). Precedentes do STJ. 4- Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag 1351403/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011) grifos nossos

Ora, estando em termos o processo, o Juiz deve julgá-lo desde logo:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder". (STJ, 4a T., REsp nº 2.832-RJ, rei. Min. Sálvio de Figueiredo, j . 14.8.1990) No mesmo sentido: RSTJ 102/500 e RT 782/302.

A preliminar se confunde com o mérito e será com ele julgada.

No mérito, a ação é procedente, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e das transações não reconhecidas após o furto do celular, para se condenar a parte requerida no pagamento de indenização por danos materiais e morais.

É cediço que operações bancárias, através de cartões e utilização de senhas pessoais, efetuadas através de meios eletrônicos podem ser realizadas de forma fraudulenta. Imperioso destacar que a relação estabelecida entre as partes litigantes, se caracteriza por sua natureza consumerista, razão porque aplicáveis os preceitos inscritos no Código de Defesa do Consumidor, notadamente os princípios da vulnerabilidade, hipossuficiência do consumidor e inversão do ônus da prova.

A parte requerida não ofertou, consoante lhe competia, nos termos do art. 434 do CPC, prova documental de idoneidade das operações bancárias e a presunção não o escusa dessa responsabilidade, sendo seu dever comprovar a autoria das operações. Referida prova documental não pode ser suprida por prova oral.

Outrossim, os documentos já existentes nos autos, comprovam que o autor não foi o responsável pelas operações descritas na inicial com o celular que foi objeto de furto, mas que houve fraude, fraude esta que é de responsabilidade das requeridas, na medida em que não manteve mecanismos de segurança adequados para evitar que terceiros realizassem o saque indevido, independentemente de os fatos terem ocorrido fora do estabelecimento bancário. Aplica-se ao caso a Súmula nº 479 do CSTJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Ao contrário do que aduz o réu, pois, a hipótese telada é do chamado fortuito interno, inerente à própria natureza da atividade bancária, que não afasta o nexo causal. Não há que se falar, pois, em exercício regular de direito por parte da ré, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, estando ausentes excludentes de

responsabilidade da ré recorrente no caso.

Diante deste contexto não é possível presumir a idoneidade das operações bancárias retratadas nesta sede e, conseqüentemente, a qualidade dos serviços prestados pela instituição-ré.

Notoriamente tem-se conhecimento da possibilidade e da ocorrência deste tipo de fraude que permite à pessoas desonestas a utilização do sistema eletrônico de forma indevida. Nesse histórico, e na medida em que há elementos de convicção que atestem a inexistência de efetiva realização das operações pela parte autora, deve-se considerar o serviço defeituoso e, portanto, acolhendo-se os pedidos na forma retro descrita, em virtude das transações indevidas, aplicando-se ao caso a inversão do ônus da prova em favor do autor, consumidor, nos termos do art.6º, VIII, da Lei nº 8.078/90.

Manifesta, pois, a falha na prestação dos serviços, ainda que o requerido se utilize de equipamentos para garantir a segurança das transações bancárias, porque referidos mecanismos foram insuficientes para coibir a fraude verificada. As transações bancárias são inexigíveis.

Deve haver, pois, o ressarcimento dos valores indevidamente sacados e movimentados na conta do autor, declarando-se também a inexigibilidade dos débitos e operações não realizadas pelo autor após o furto do celular.

Entendo também pelo cabimento do pedido de condenação do requerido no pagamento de indenização por danos morais, aplicando-se ao caso a teoria do desvio produtivo diante do transtorno e aborrecimento sofrido pela parte autora.

Vem sendo reconhecida na jurisprudência, a teoria do desvio produtivo do consumidor, que identifica o prejuízo do tempo desperdiçado pelo consumidor para solucionar problema criado pelo próprio fornecedor, situação esta que sobressai o simples aborrecimento, para afetar o sossego, a tranquilidade e, assim, situar no terreno dos danos morais.

O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável (Marcos Dessaune citado no artigo "Tempo gasto em problema de consumo deve ser indenizado" - <http://www.conjur.com.br/2014-mar-26/tempo-gasto-problema-consumo-indenizado-apontam-decisoes>).

Assim já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO DO PRODUTO - Máquina de lavar - Aquisição em decorrência de a consumidora ser portadora de 04 (quatro) hérnias discais extrusas e, por orientação médica, foi privada de realizar esforços físicos - Inúmeras tentativas de resolução do problema que restaram infrutíferas (grifei) - Tentativa de resolução por intermédio do processo administrativo junto ao Procon, onde avençou-se acordo que não foi cumprido pelo fornecedor - Nítida ocorrência do - Venire contra factum proprium - Fixação de cláusula penal - Dano material que não se confunde com o dano moral - Tempo demasiado sem o uso do referido produto - Desídia e falta de respeito para com o consumidor - Tempo perdido do consumidor para tentativa de solução do infortúnio, que acarreta dano indenizável - Inteligência da tese do Desvio Produtivo do Consumidor. Danos morais Configurados. Afronta à dignidade da pessoa humana Caso dos autos que não se confunde com um mero aborrecimento do cotidiano - Indenização fixada em R\$5.000,00 (cinco mil reais). Sentença de improcedência reformada. Recurso provido." (Apelação 0007852-15.2010.8.26.0038 - 5ª Câmara de Direito Privado - Rel. Fabio Podestá - j. 13.11.13).

Aplicável analogicamente ao caso os seguintes entendimentos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Fraude bancária - Ação de indenização por danos materiais em razão da falha na prestação de serviços - Realização de operações bancárias não autorizadas a partir da conta da Autora - Operações bancárias não reconhecidas pela titular - Falha na prestação dos serviços - Responsabilidade do Banco Réu configurada - Súmula nº. 479, do C. Superior Tribunal de Justiça - Determinação de restituição dos valores indevidamente

transferidos e não restituídos - Danos morais configurados - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1025073-80.2019.8.26.0554; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021)

Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenizatória por danos morais. Cartão de crédito. Operações contestadas, pois realizadas através do celular ao autor, furtado na mesma data. Réu que não comprovou a lisura das operações.

Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo nº 1.199.782/PR e Súmula nº 479, ambos do E. STJ. Dano moral configurado. Teoria do Desvio Produtivo. Quantificação da verba indenizatória, com consideração dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000139-28.2020.8.26.0003; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020)

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS - Furto de celular que continha o aplicativo para movimentação da conta corrente - Verificada a existência de várias operações financeiras que não foram reconhecidas pela sua titular - Instituição financeira que não efetuou o devido controle da movimentação da conta corrente da cliente, e que permitiu operações que destoam do perfil da correntista sem as devidas cautelas - Nexo causal demonstrado - Falha na prestação de serviço - Dano moral caracterizada que deve ser indenizado - Valor da indenização que bem remunera o dano sofrido - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1011574-96.2020.8.26.0100; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020)

Apelação. Serviços bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e a indenização por danos morais. Relação de consumo que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC) e inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII do CDC). Autora que foi vítima de furto. Operações de empréstimo e saques, em curto período de tempo e desconexas com o perfil da vítima. Responsabilidade das instituições bancárias pela fiscalização das operações suspeitas de consumo. Ausência de prova de que os saques e empréstimo foram realizados pela parte autora. Falha na prestação do serviço (art. 14, §1º do CDC). Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (S. 479 do STJ). Débito inexigível, devida restituição. Dano moral configurado. Indenização mantida. Majoração dos honorários da advogada da autora a ser suportada pela ré recorrente (vencida). Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1048007-36.2019.8.26.0100; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020)

"RESPONSABILIDADE CIVIL. Transações não autorizadas realizadas após furto de celular - Sentença de parcial procedência - Inconformismo de ambos litigantes - Ilegitimidade passiva da casa bancária afastada - Réu que é banco totalmente digital e afirma ter sido comunicado do furto cinco minutos depois da TED, quando o cartão foi bloqueado - Autora que alega ter comunicado o banco uma hora depois do furto, quando não havia notícia de nenhuma transação realizada - Se havia transcorrido apenas cinco minutos de uma TED haveria sim a possibilidade de reversão imediata, com pedido de bloqueio da agência bancária de destino do Itaú, para que referido valor não fosse movimentado, até que se confirmasse a fraude e devolvesse à vítima - Banco réu que não demonstrou sequer qualquer comunicação ou contato com a agência de destino do valor questionado - A informação de que o celular da requerente estava desbloqueado não é suficiente para imputar a ela a responsabilidade pela fraude sofrida, pois que bem provável que ele estaria em uso quando foi furtado - Ainda que estivesse bloqueado, ao que se tem notícias, as quadrilhas já sabem atuar de modo a alterar as senhas e reconhecimento facial para desbloqueio dos aparelhos - Não há aqui demonstração de que a segurança empregada para evitar fraudes por parte da casa bancária tem sido com excelência, pois ao que

consta até mesmo das razões de recurso, a modificação da senha do aplicativo bancário, com acesso imediato ao e-mail para alteração de senha revela-se primário - Sequer existe redução preventiva e imediata de limites de transação por 24 horas ou 48 horas, quando ocorre a alteração de senha, justamente pela suspeita de fraude e a crescente ocorrência deste tipo de crime, que não poderia ser desconhecida pela casa bancária - Fragilidade do sistema bancário do réu, especialmente do gerenciamento do sistema de alteração de senhas e segurança do sistema para evitar fraudes, além da ausência de ação imediata para evitar a TED, que tinha acabado de ser realizada - Responsabilidade que deve ser imputada ao requerido - Casa bancária que não comprovou ter realizado qualquer investigação administrativa para apurar o ocorrido, deixando o consumidor à deriva - Cumpria ao banco apelante comprovar que a transação questionada foi realizada pela autora ou em seu proveito, nos termos do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, ônus que lhe competia - Falha na prestação de serviços que causou danos ao correntista - Dano moral configurado - Valor a título de danos morais que merece ser majorado - Sentença reformada para elevação dos danos morais para R\$ 10.000,00 - Não provido o apelo do banco réu e parcialmente provido o recurso da autora. (TJSP; Apelação Cível 1057505-91.2021.8.26.0002; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2022; Data de Registro: 19/05/2022)"

"AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONSUMIDOR. ROUBO DE CELULAR CONTENDO APLICATIVO DO BANCO RÉU. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. Consumidor vítima de roubo de celular. Terceiro que logrou, via aplicativo da instituição financeira, fazer indevida movimentação na conta corrente. Transferência entre contas no montante de R\$. 9.663,099. O autor não forneceu a senha a terceiros. A questão se localizava na falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso dos criminosos, via aplicativo, à senha da conta corrente do autor e sua movimentação. Nem se diga que à autora cabia também a comunicação ao banco réu para se evitar uso do aplicativo e acesso à conta corrente. o acesso ao aplicativo se dava por reconhecimento facial e em algum momento esta tecnologia falhou, visto que os criminosos tiveram acesso aos dados bancários do consumidor. Faltou segurança ao serviço bancário via aplicativo. Sua fragilidade viabilizou o indevido acesso dos fraudadores, porquanto o autor viu seu celular roubado sem que tivesse fornecido qualquer dado (senha ou número de conta corrente). E, o autor providenciou a desativação do Token (i-safe) vinculado ao aplicativo do banco réu. Todavia, ainda sim, após tomar essa medida de precaução, os criminosos lograram êxito no golpe. Na instrução do processo, constatou-se a inexistência de qualquer ato, culposos ou dolosos, por parte do consumidor. Transações fugiam ao perfil do próprio autor. Antes mesmo das transações efetuadas, o agente criminoso requereu modificações na conta do autor que deveriam despertar no sistema de segurança do banco réu um alerta para se evitar a concretização das transações fraudulentas Incidência da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do réu configurada. Danos materiais reconhecidos. Indenização no valor de R\$ 9.663,99 mantida. Danos morais reconhecidos. O consumidor experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação. Indenização fixada em R\$ 5.000,00. Ação procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1068955-28.2021.8.26.0100; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2022; Data de Registro: 04/07/2022)"

Nestes termos, para o fim de compensar a vítima, como forma de atenuar a lesão e com o fito de inibir o réu a prática de atos como os aqui retratados, reputo suficiente e adequada a indenização no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), apto a satisfazer o dano experimentado pela parte autora e coibir o réu na incidência do mesmo procedimento.

Diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo procedentes

os pedidos da ação promovida, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art.487, I, do CPC, para condenar a parte requerida no pagamento de indenização por danos materiais, estes últimos consistentes na devolução dos valores transferidos indevidamente, no importe descrito na inicial, quantia esta que deverá ser devidamente corrigida pela T.P.T.J., desde o ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês devidos desde a citação, condenando-se a requerida ao pagamento, à parte autora, de indenização por danos morais, no importe de R\$ 5.000,00, devidamente corrigidos pela T.P.T.J., desde a data desta sentença (Súmula nº 362 do CSTJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês devidos desde a citação, confirmando-se a tutela antecipada deferida, declarando-se a inexistência de relação jurídica entre o Autor e o Banco Réu quanto aos empréstimos indevidamente realizados pelos fraudadores.

Diante da sucumbência arcará a requerida com as custas e despesas, bem como com o pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, fixados no valor total de 10% sobre o valor da causa, nos termos dos arts.85, § 2º e 85, § 14 do NCPC.
P.R.I.C.

São Paulo, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA